SENTENÇA

Processo: 0804782-45.2024.8.19.0204

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: JOAO MARCELO ALVES MERCADANTE

RÉU: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

João Marcelo Alves Mercadante propôs a Ação de Obrigação de Fazer em face de Vision Med Assistência Médica LTDA., nos termos da petição inicial de Id. 105067245, que veio acompanhada dos documentos de Id. 105069856/105069900.

Através da decisão no Id 105169099, foi deferida a tutela antecipada.

Citada, a parte ré apresentou sua contestação no Id. 109959372, instruída com os documentos de Id. 109959379/109959380.

Réplica apresentada no Id. 123481725.

RELATADOS. DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as preliminares suscitadas pela parte ré se confundem como próprio mérito da causa, razão pela qual serão analisadas no decorrer deste trabalho.

Através da presente ação pretende a parte autora alcançar a indenização pelos danos que lhe foram causados por força de comportamento indevido perpetrado pela parte ré.

Segundo exposto na inicial, o autor é portador de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO com SÍNDROME NEFRÍTICA CRÔNICA e ANEMIA HEMOLÍTICA AUTIMUNE, necessitando do uso contínuo do medicamento BENLYSTA –

BELIMUMABE com intuito de evitar a piora do quadro articular e do desenvolvimento de doença renal crônica.

Destacou ser usuário do plano de saúde administrado pela empresa ré e que, ao longo dos meses, sempre honrou com o cumprimento de suas obrigações.

Contudo, para a sua surpresa, ao solicitar a autorização para a liberação do tratamento com o consequente custeio, viu negado o seu intento sob o fundamento de que se trata de medicamento não incluído no rol da ANS.

A parte ré, por sua vez, asseverou a ausência de qualquer comportamento indevido, tendo, na realidade, agido respaldada no regular exercício de seu direito, notadamente diante do fato de a moléstia que vitimou o autor – LÚPUS – não se encontra inserida na cobertura do plano de saúde.

Outra questão ventilada pela parte ré foi que, não obstante o autor, quando do preenchimento de sua declaração de saúde, ter afirmado não ser portador de doença preexistente, o mesmo já havia sido internado em julho de 2023 e, na ocasião, foi efetuada anotação médica no sentido de que já era portador da moléstia LÚPUS há aproximadamente 12 (doze) anos, submetendo-se, inclusive, ao uso de medicamento.

Assim, a seu ver, em tendo o autor sido admitido no plano de saúde em questão em abril de 2023, já tinha conhecimento da doença que o vitimou e a omitiu quando do preenchimento de sua declaração de saúde.

Ao mesmo tempo, o medicamento solicitado não se encontra inserido no rol de procedimentos ditados pela ANS.

Neste momento, insta tecer certas considerações acerca da responsabilidade civil.

Analisando minuciosamente a delicada situação trazida à baila, verifica-se que a mesma representa uma nítida relação de consumo, eis que tanto a parte autora, como a parte ré se caracterizam, respectivamente, como consumidora e fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º, parágrafos 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor, *in verbis*:

> "**Art. 2º**: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
>
> "**Art. 3º**: (...) **Parágrafo primeiro** –Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. **Parágrafo segundo** - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Assim, diante da relação jurídica firmada entre as partes, pode-se afirmar que o réu colocou os seus serviços à disposição da Sociedade, razão pelo qual não pode se colocar à margem do Direito do Consumidor, aplicando-se, em sua plenitude, os ditames de ordem pública consagrados no referido diploma legal.

Igualmente importante destacar o teor da Súmula 608, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

> "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Outra observação a ser efetuada é que se sobressai o fato de que os serviços da parte ré estão no mercado de consumo, encontrando-se regido pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos que tais serviços possam ter causado, nos termos do artigo 6º, VI, do referido diploma legal, *in verbis*:

> "**Art. 6º**. São direitos básicos do consumidor: (...) **VI** - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

Também não se pode deixar de mencionar que se aplica à parte ré a Teoria do Risco do Empreendimento. Assim, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência da culpa.

Segundo expõe o ilustre Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra "Programa de Responsabilidade Civil", 1ª Edição – 2ª Tiragem, Malheiros Editores, "(...) este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de (...) executar determinados serviços" (p. 318).

Por derradeiro, a parte ré, na qualidade de prestadora de serviços, se obriga a prestá-los de forma adequada e eficiente, de sorte a não causar nenhum tipo de dano ao consumidor, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados ao mesmo.

Ainda incidem no vertente caso os ditames do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, impondo à parte ré a responsabilidade de natureza objetiva, onde não se discute a culpa.

Por via de consequência, a sua responsabilidade somente pode ser afastada diante de hipóteses que excluam o nexo causal, hipóteses estas que se encontram disciplinadas no parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal citado.

Desta forma, para que surja tal responsabilidade da parte ré, basta que se demonstre, de forma cabal e induvidosa, a existência do dano, bem como o nexo causal.

O primeiro elemento acima identificado, qual seja, o dano, pode ser conceituado como sendo a subtração ou diminuição de um bem jurídico tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial ou integrante da própria personalidade da vítima. Sem tal elemento não há de se falar em indenização ou ressarcimento. Daí se conclui que o dano é o elemento preponderante da responsabilidade civil.

O último elemento, também importante para gerar a responsabilidade civil, é o nexo causal, vale dizer, a relação de causa e efeito entre o comportamento culposo e o dano. Assim, chega-se à inarredável conclusão de que o dano deve ser consequência direta e imediata do ato culposo que lhe deu causa.

O intuito do legislador, ao consagrar a responsabilidade objetiva se deu diante da notória hipossuficiência do consumidor, parte mais fraca na relação de consumo e diante do fato de que, dentre seus direitos fundamentais, consagrados no Código Protetivo, se encontra o de facilitar o seu acesso aos meios de defesa.

Também há de se destacar a aplicação, ao vertente caso, das normas contidas nos artigos 47 e 54, parágrafos terceiro e quarto, do diploma legal acima mencionado, *in verbis*:

> "**Art. 47** – As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".
>
> "**Art. 54** (...). **Parágrafo 3º** – Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. **Parágrafo 4º** – As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão".

Justifica-se tal preocupação, pois, conforme é de sabença trivial, o contrato de adesão se caracteriza como sendo um contrato-padrão, já impresso, onde as suas cláusulas são estipuladas unilateralmente, vale dizer, por uma das partes contratantes, e submetidas à aceitação da outra parte que, tendo necessidade de contratar, firma o pacto sem dispensar maiores atenções para as disposições contratuais.

Ao mesmo tempo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, *caput*, definiu o contrato de adesão como sendo "(...) aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo".

Comentando o dispositivo legal em foco, a respeitável Ada Pellegrini Grinover, em sua obra "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto", expõe a sua preocupação no que tange aos contratos de adesão, esclarecendo que "(...) o Código consagrou o *princípio da legalidade das cláusulas contratuais*. O dispositivo visa a permitir que o consumidor possa tomar conhecimento do conteúdo do contrato pela simples leitura, sem prejuízo do dever de esclarecimento por parte do fornecedor. (...) A redação em caracteres legíveis possibilita diminuir o âmbito de controle das cláusulas contratuais gerais, qualitativa e quantitativamente, além de consistir em instrumento de segurança das seguranças jurídicas e de liberdade contratual (...)" (p. 553).

Ao citar comentários acerca do disposto no artigo 54, parágrafo quarto, a ilustre Ada Pellegrini Grinover expõe que "(...) toda estipulação que implicar qualquer *limitação de direito* do consumidor, bem como a que indicar *desvantagem ao aderente*, deverá vir simplesmente exposta, do ponto de vista físico, no contrato de adesão. (...) Deverá chamar a atenção do consumidor para as estipulações desvantajosas para ele, em nome da boa-fé que deve presidir as relações de consumo (...)" (p. 554).

Pode-se, portanto, afirmar que a empresa ré está obrigada ao cumprimento de uma boa-fé qualificada, ou seja, uma boa-fé que pressupõe os deveres de informação, cooperação e cuidado com o consumidor.

Levando-se, ainda, em conta a finalidade do contrato em foco, que visa, precipuamente, assegurar ao consumidor e seus dependentes contra os riscos relacionados com a saúde e a manutenção da vida, conclui-se que a sua característica principal é o fato de envolver serviços (de prestação médica ou de seguro) de trato sucessivo, ou seja, contratos de fazer, de longa duração, e que possuem uma grande importância social e individual.

Trata-se, portanto, de serviços que prometem segurança e qualidade, serviços cuja prestação se protrai no tempo, de trato sucessivo, com uma fase de execução contratual longa e descontínua, de fazer e não fazer, de informar e não prejudicar, de prometer e cumprir, de manter sempre o vínculo contratual e o usuário cativo.

Voltando ao caso concreto, constata-se, através da documentação que instruiu a inicial, que a parte autora é usuária do plano de saúde administrado pela empresa ré, inexistindo qualquer débito pendente.

Igualmente constatado, através do laudo médico (ID 105069864), ser o autor portador de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO com acometimento renal, artrite, miosite e anemia hemolítica autoimume ao diagnóstico.

Igualmente constatado, pelo referido laudo médico, que a medicação anteriormente prescrita não surtiu os benefícios almejados, razão pela qual lhe foi prescrito o medicamento BENLYSTA – BELIMUMABE.

Acerca de sua eficácia, a médica responsável pelo tratamento do autor, Dra. MARINA DO CARMO PORANGABA destacou que “(...) devido à ação nefroprotetora da BELIMUMABE, além do benefício no quadro articular, está indicado início desta medicação para controle da doença do paciente com o objetivo principal de prevenir a evolução para doença renal crônica (...)” (ID 105069864).

É certo que a parte ré, quando de sua contestação, asseverou que a recusa restou legítima, tendo, na realidade, agido respaldada no regular exercício de seu direito.

Entretanto, diante da documentação que instruiu a inicial, notadamente o laudo médico acima discriminado e a necessidade do uso do medicamento BENLYSTA – BELIMUMABE, não lhe assiste razão.

Primeiramente, porque não há nenhum documento dando conta da exclusão da moléstia que, infelizmente, vitimou o autor do plano de saúde em foco.

Não se pode deixar de repetir que pactos desta natureza (adesão) têm suas cláusulas fixadas de modo unilateral pelo fornecedor, razão pela qual devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, do diploma consumerista.

Analisando o instrumento contratual que instruiu a contestação, observa-se que o plano médico do autor tem por objeto a assistência à saúde de seus associados, na forma de cobertura de despesas com serviços médico hospitalares, exames complementares, serviços auxiliares de diagnose e terapia, tratamentos especializados e procedimentos especiais, condicionados ao atendimento das regras, critérios e condições previstas no Regulamento em foco.

Portanto, não se verifica nenhuma cláusula que expressamente exclua o dever de cobertura do tratamento da doença que acomete a parte autora.

E certo que, pelo que se depreende do teor de sua cláusula nona (ID 109959376), existe previsão de exclusão das coberturas excluídas do rol de procedimentos da ANS.

Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 51, inciso IV e parágrafo primeiro, que a cláusula de exclusão de serviço/tratamento, é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, visto que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto e/ou equilíbrio contratual.

A propósito, o verbete nº 340 da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

> "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano".

Outrossim, cumpre salientar que compete ao médico responsável, que possui condições técnicas para ministrar a terapêutica ideal e os medicamentos imprescindíveis ao restabelecimento da saúde de seu paciente, determinar o tratamento adequado e indicado, e não ao plano de saúde contratado, conforme pacificado na Súmula nº 211 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

> "Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização".

Por conseguinte, a recusa da cobertura integral do tratamento requerido pelo médico assistente, constitui, no entender desta magistrada, conduta abusiva.

Acerca da previsão de aplicação do fármaco BENLYSTA para o tratamento da patologia em discussão, observa-se que há indicação específica para o caso de pacientes adultos com LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO ATIVO, como é o caso do autor.

A alegação da parte ré de que a negativa foi válida porque a aplicação do BENLYSTA para o tratamento de LÚPUS não está explicitado no rol das Diretrizes da ANS, não merece prosperar.

Isso porque o rol da ANS se constitui em mero parâmetro de análise, vez que sempre é atualizado com o escopo de acompanhar os avanços da Medicina e as recentes modalidades de tratamento.

Inclusive, a questão foi apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos EResp nº. 1.886.929/SP e EResp nº. 1.889.704/SP, no sentido de rol da ANS ser de taxatividade mitigada, conforme a seguir exposto:

> "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva *ad causam* da ANS".

Assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o rol da ANS é, via de regra, taxativo, podendo, todavia, ser determinada a cobertura obrigatória de tratamento não incorporado se superadas todas as alternativas constantes do rol, sem sucesso, desde que a medida não tenha sido expressamente excluída pela ANS e com comprovação científica de eficácia comprovada.

Ademais, foi editada a Lei nº. 14.454/2022, que alterou a Lei nº. 9.656/98 exatamente para enfrentar a discussão do rol taxativo da ANS, sendo determinada a obrigação de cobertura de medida não prevista no rol desde que prescrita pelo médico assistente, e que exista comprovação de eficácia ou recomendação de órgão de renome internacional. Eis o teor do art. 10, parágrafo décimo terceiro, da Lei nº. 9.656/98, com redação dada pela Lei nº. 14.454/2022:

> "**Art. 10**: (...) **Parágrafo décimo terceiro**: Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: **I** - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou **II** - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais".

Na hipótese em tela, conforme mencionado ao longo deste trabalho, o laudo médico (ID 105069864) bem demonstrou ser o autor portador de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO com acometimento renal, artrite, miosite e anemia hemolítica autoimume ao diagnóstico, apresentando-se imprescindível o medicamento BENLYSTA – BELIMUMABE para o benefício no quadro articular, controle da doença e prevenir a evolução para doença renal crônica.

Portanto, não se justifica a conduta perpetrada pela empresa ré.

Imperioso concluir que há dever de cobertura pela ré para o tratamento do autor com o medicamento BENLYSTA, a uma, porque a doença não está excluída no contrato; a duas, porque o tratamento foi prescrito por sua médica assistente; a três, porque se trata de medicamento indicado para o tratamento de LÚPUS.

Neste sentido, vale a pena trazer à lume os seguintes julgados:

> "APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES REQUERIDAS. CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSOS VOLTADOS CONTRA OS FUNDAMENTOS COLIGIDOS NA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL 1 – INSURGÊNCIA DA RÉ UNIMEDO-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. PRELIMINAR DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO INICIAL – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O MEDICAMENTO DENOMINADO BELIMUMABE - BENLYSTA NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) – ROL DA ANS QUE TEM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE MÉRITO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E CONTRATOU PLANO DE SAÚDE PARTICULAR – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EVIDENCIADA – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR QUE, DE PER SE, NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DENOMINADO BELIMUMABE - BENLYSTA – PEDIDO NO SENTIDO DE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO ACOLHIMENTO – MEDICAMENTO QUE DEVE SER ADMINISTRADO POR PROFISSIONAL HABILITADO – ROL DA ANS QUE TEM CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – LIMITAÇÃO DO RISCO QUE FERE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, EQUIDADE E RAZOABILIDADE – DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, PARA QUE SEJAM APRESENTADOS RELATÓRIOS MÉDICOS SEMESTRAIS, OS QUAIS DEMONSTREM A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – ENUNCIADO Nº 2 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL

DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – PEDIDO NO SENTIDO DE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECUSA ADMINISTRATIVA DA OPERADORA INSUFICIENTE PARA GERAR ABALO PSICOLÓGICO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO COMPROVA O AGRAVAMENTO DO SEU ESTADO DE SAÚDE, OU OUTRA CONSEQUÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2 – INSURGÊNCIA DA RÉ UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS. PRELIMINAR DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA OPERADORA UNIMED-RIO E DE QUE AS OPERADORAS DESIGNADAS PELA UNIMED NÃO TÊM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SI – OPERADORAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUESTÃO APRECIADA NO RECURSO DE APELAÇÃO 1, INTERPOSTO PELA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. – ANÁLISE PREJUDICADA – NÃO CONHECIMENTO.RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBNECIAL EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES" (TJPR, Apelação Cível n. 0002079- 73.2020.8.16.0019, Nona Câmara Cível, Relator: Desembargador GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu antecipação de tutela para compelir a operadora de saúde a fornecer o medicamento Belimumabe 400mg para tratamento de Lúpus Eritematoso

Sistêmico. Insurgência da requerida. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal. Aplicação ao caso da legislação consumerista. Inteligência da Súmula nº 608 do E. STJ. Agravada em tratamento de doença autoimune, degenerativa, em franco progresso, não combatida com uso dos medicamentos convencionais, conforme relatório acostado aos autos originários. Inteligência das Súmulas n° 102 e 95 deste Egrégio TJSP, bem como do art. 35-F da Lei nº 9.656/98. Perigo da demora configurado ante o iminente risco de agravamento do quadro da paciente. Preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2004106-97.2025.8.26.0000, Décima Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador COELHO MENDES).

"Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Pretensão de fornecimento de medicamento "belimumabe" para tratamento de "Lupus Eritematoso Sistêmico". Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. Negativa baseada na alegação de que o tratamento não se encontra previsto nas diretrizes do rol da ANS. Abusividade à luz da legislação consumerista reconhecida. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico. Medicamento registrado na Anvisa. Inteligência da Súmula 102 deste Tribunal. Uso domiciliar que não afasta a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, uma vez que sua utilização é feita sob orientação médica que, necessariamente, receitará e acompanhará os resultados do tratamento, sendo que tal procedimento apresenta um custo menor para a seguradora, que não dispenderá gastos com a internação. Precedentes desta Câmara. Manutenção da condenação da ré no pagamento de indenização por morais, uma vez que, conforme já decidido pelo C. STJ, a negativa ilegítima e abusiva de procedimento médico por parte da operadora de plano de saúde causa dano moral ao segurado, pois lesionao no direito da personalidade, relacionado à

> integridade psíquica, extrapolando o plano do chamado "mero dissabor". Quantum indenizatório fixado com razoabilidade. Recurso não provido" (TJSP, Apelação Cível n. 1007617-78.2023.8.26.0554, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador EMERSON SUMARIVA JÚNIOR).

Não se pode deixar de repetir que o direito à vida e a manutenção da saúde são absolutos, devendo prevalecer sobre estipulações contratuais que limitam a sua abrangência, tornando-se abusivas as cláusulas contratuais, ainda que inseridas com destaque no contrato, que causem manifesta desvantagem ao usuário, notadamente diante da gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade da utilização do medicamento em questão muito bem destacada pelo próprio médico responsável pelo seu tratamento.

Neste diapasão, aplicando-se os princípios citados no início deste trabalho, não se justifica, e tampouco encontra amparo legal, o comportamento do réu. Conferindo legalidade ao seu comportamento, estar-se-ia admitindo que a parte autora permanecesse ao desamparo, quando, efetivamente, necessitou da prestação dos serviços que buscou contratar.

É certo que a parte ré, quando de sua contestação (ID 109959372), asseverou que o autor tinha plena ciência de sua doença preexistente ao contrato firmado.

Entretanto, da análise dos documentos juntados aos autos (notadamente o laudo médico ID 105069864), verifica-se que o autor, quando da contratação do plano de saúde (março 2023) ainda não tinha ciência da moléstia que o acometeu.

Inclusive, segundo convicção desta magistrada, a suspeita ou até mesmo os sintomas apresentados não significa a existência necessariamente de uma doença, não havendo que se falar em omissão de informações ou mesmo que tenha o autor agido de má-fé.

Outra observação a ser efetuada é que a administradora do plano de saúde, ora ré, não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, bem como não logrou êxito em apresentar prova inequívoca de má-fé do consumidor (decorrente da omissão intencional de doença preexistente), conforme orientação firmada na Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

> "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

No presente caso, além de a parte ré não ter exigido exames médicos prévios à contratação do serviço de assistência à saúde, igualmente, não comprovou a suposta má-fé do autor.

Saliente-se que, conforme princípio geral do direito, a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada cabalmente nos autos para que seja possível imputar ao agente os efeitos dela decorrentes.

Desse modo, diante da documentação carreada aos autos, não se pode afirmar categoricamente que à época da celebração do contrato, a parte autora já apresentava o diagnóstico de LÚPUS.

Assim, considerando a impossibilidade de simplesmente se presumir a má-fé da parte contratante (ora autor) e a inexistência de acervo probatório capaz de comprovar o atuar doloso da parte autora, a parte ré agiu de forma indevida ao recursar o medicamento prescrito pelo médico assistente e que se fazia necessário para a melhoria de seu estado de saúde.

Em situações bastante semelhantes à ora estudada, urge trazer à lume os seguintes julgados oriundos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

> “PLANO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE - SUSPEITA DE MALIGNIDADE - DIVERSIDADE DA CIÊNCIA DO CISTO BENIGNO - ACEITAÇÃO NO PLANO SEM PEDIDO DE EXAMES - RISCO COBERTO. Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de realização de procedimento denominado "MAMOTOMIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA" sob o argumento de omissão quanto à doença preexistente. A sentença ratificou a tutela e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, arbitrando honorários em 10% sobre o valor da condenação. Apela a ré requerendo a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, que a verba reparatória seja fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não vislumbrada omissão da autora quanto à existência de doença preexistente. Ausência de conhecimento da extensão do mal pelo consumidor. Exame realizado próxima a contratação que indica a existência de tumor benigno. Existência de plano anterior com operadora diversa que rechaça a contratação exclusiva para fins de realização do procedimento negado. Aceitação da declaração de saúde sem realização de exames. Doença maligna afastada em decorrência da realização de exame por força de medida antecipatória. Recusa indevida. Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral configurado. Recusa do tratamento que traz efetivo temor ao consumidor diante da recusa a realização de procedimento apto a avançar a investigação do médico no sentido de afastar o temor quanto ao quadro instalado, além de a ré enviar telegramas indicando a instauração de procedimento administrativo junto à ANS. RECURSO DESPROVIDO” (TJRJ, Apelação Cível n. 0001991-04.2017.8.19.0004, Vigésima Sexta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA).
>
> “Ação de conhecimento proposta por operadora de plano de saúde objetivando o cancelamento do contrato celebrado com a Ré em razão da omissão de doença preexistente, além do ressarcimento das despesas relacionadas a qualquer procedimento/tratamento realizado pela beneficiária para tratamento de lesões e doenças preexistentes não declaradas. Reconvenção da Ré objetivando a manutenção do contrato de plano de saúde com a autorização da realização do exame de cintilografia óssea cuja autorização lhe foi negada, e indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 20.000,00. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente, em parte, o pedido reconvencional para condenar a Autora-Reconvinda ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, determinando o rateio das despesas processuais em partes iguais e arbitrando os honorários advocatícios para os patronos da Autora e da Ré. Apelação de ambas as partes. Prova documental que demonstrou a ausência de assinatura na declaração de saúde da beneficiária. Beneficiária que afirmou em depoimento pessoal que informou à preposta da Autora-Reconvinda a doença preexistente. Eventual existência de fraude que deve ser imputada à preposta da Autora-Reconvinda. Inexistência de máfé da consumidora, não havendo que se falar em rescisão por fraude, nem em reembolso de valores despendidos pela operadora de plano de saúde. Dano moral configurado. Quantum da indenização fixado em

montante compatível com a repercussão dos fatos narrados nos autos. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. Juros de mora corretamente computados a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual. Despesas processuais que devem ser impostas por inteiro à Autora-Reconvinda que decaiu de porção maior do pedido. Desprovimento da primeira apelação e provimento parcial da segunda apelação" (TJRJ, Apelação Cível n. 0002488-64.2017.8.19.0021, Vigésima Sexta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA).

Neste diapasão, aplicando-se os princípios citados no início deste trabalho, não se justifica, e tampouco encontra amparo legal, o comportamento da parte ré.

De se ressaltar que o contrato deve se ajustar aos avanços da medicina, cabendo ao profissional da área, a indicação do tratamento adequado ao seu paciente, não se admitindo interferência da seguradora para este fim, sob pena de violar o próprio objeto contratado, qual seja, a proteção da vida e da saúde do beneficiário.

Ora, se o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acometeu a autora, sendo de rigor a cobertura do tratamento indicado, não se reputa plausível a negativa, sob pena de torná-lo ineficaz ao seu objetivo.

Repita-se que cabe ao médico prescrever o tratamento mais adequado a cada paciente, tomando em consideração a maior ou menor extensão da doença, bem como a gravidade ou não do quadro clínico apresentado e as demais circunstâncias capazes de influenciar na recuperação da saúde. Por conseguinte, a operadora de plano de saúde não pode se imiscuir na esfera de atuação, que é própria do médico que assiste o doente, pois é ele quem conhece sua patologia e a real necessidade de realizar o tratamento.

A exclusão de tratamento essencial à saúde, seja por cláusula limitativa ou não, nada mais representa do que uma velada forma de incumprimento contratual, tendo restado evidente o abalo à dignidade da parte autora, uma vez que a conduta da parte ré impôs angústia, desamparo e ansiedade, gerando o dano moral indenizável.

Valendo-se das sábias lições do ilustre e culto Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra "Programa de Responsabilidade Civil", 1ª Edição – 2ª Tiragem, Editora Malheiros, "(...) só pode ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar (...)" (p. 76).

Ora, de acordo com a narrativa da parte autora, somada à prova carreada aos autos, salta aos olhos o abalo psicológico ao qual o ilustre Desembargador fez menção em sua notável obra, abalo este, conforme já mencionado ao longo deste trabalho, se presume diante da própria situação descrita.

É certo que a jurisprudência vem se filiando no sentido de que o simples inadimplemento contratual não dá ensejo a indenização por danos morais; contudo, abre-se uma exceção para o caso em que o referido inadimplemento resultar violação ou agravamento da interferência indevida na esfera da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da vítima.

Realmente, é desesperador quando, no momento em que mais se precisa de um plano de saúde, o qual se filiou depositando confiança e esperando segurança, seja, o consumidor, frustrado em tal expectativa por uma situação que lhe é estranha.

Torna-se imperioso ressaltar que o dano moral, em situações como a do caso em tela se presume, de modo que, à parte autora, basta a alegação, ficando à cargo da outra parte a produção de provas em contrário, o que, no vertente caso, não ocorreu.

Neste particular, o ilustre Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", 4ª Edição – 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, esclarece que "(...) a causação de dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. (...) Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, dispensável ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo (...)" (p. 722).

Também não se pode deixar de trazer à baila a lição esposada pela ilustre e respeitável Maria Helena Diniz, em sua obra intitulada "Curso de Direito Civil Brasileiro", 7º volume, 9ª Edição, Editora Saraiva, ao tratar do dano moral, ressalva que a reparação tem sua dupla função, a penal "(...) constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa (integridade física, moral e intelectual) não poderá ser violado impunemente (...)", e a função satisfatória ou compensatória, pois "(...) como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa a proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada (...)".

Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento do dano moral, decorrente da própria situação descrita na inicial, surgindo, portanto, para a parte ré, a obrigação de compensar, a parte autora, pelo inegável abalo sofrido.

Inclusive, não se pode deixar de trazer a lume o teor da Súmula n. 339, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que assim dispõe:

> "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral".

Com efeito, a indenização, por possuir caráter dúplice - compensatório e repressivo – deve ser fixada levando-se em consideração o sofrimento da vítima e capacidade econômica das partes, a fim de não se constituir fonte de enriquecimento indevido.

Neste diapasão, impõe-se a acolhida da pretensão autoral por ser a expressão da mais límpida e cristalina justiça.

Isto posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, tornando definitiva a tutela antecipada concedida (ID 105169099). Condeno a parte ré ao pagamento, em favor da parte autora, da indenização a título de danos morais, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida dos juros legais desde a efetiva citação e monetariamente corrigida a partir da presente data.

Condeno a parte ré, como decorrência da sucumbência, ao pagamento das custas processuais, devidas por força de lei, bem como dos honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.

RIO DE JANEIRO, 29 de janeiro de 2025.

FLAVIA GONCALVES MORAES BRUNO
Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: FLAVIA GONCALVES MORAES BRUNO
29/01/2025 17:49:56
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25012917495670700000160467079

IMPRIMIR GERAR PDF